

1500923-72.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... réu é acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas.

Os guardas civis municipais que o abordaram, Sandro Henrique do Nascimento e Devanir Moreira dos Santos, narraram em sede policial que se deslocavam entre dois pontos públicos quando, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, presenciaram dois indivíduos em atitude suspeita, típica da mercancia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500923-72.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500923-72.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Cláudio Ferreira da Silva

Réu Preso

Vistos.

Cláudio Ferreira da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de julho de 2022, por volta de 15h10min, na Rua Antônio José Carneiro de Souza nº 250, bairro Belém, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, cinquenta e oito invólucros de plástico transparente contendo cocaína sob a forma de crack, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia que guardas civis municipais faziam patrulhamento de rotina quando se depararam com o réu e um terceiro em atitude típica de venda de drogas, posto que o réu conversava com o motorista de um veículo estacionado no local. Resolveram abordá-los. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com a pessoa que estava dentro do automóvel. Todavia, nas vestes do réu foram localizadas seis porções de crack e R\$325,60 em dinheiro. Ao lado do réu também foi localizado um maço de cigarros contendo outras cinquenta e duas porções de crack, embaladas da mesma forma daquelas localizadas em seu poder, prontas para a venda. O réu limitou-se a negar a propriedade das drogas e do dinheiro, sendo-lhe dada ordem de prisão (fls. 94/95).

Recebida a denúncia, em 05 de agosto de 2022 (fls. 98/101), o réu foi citado (fls.

147) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 156).

Saneado o processo (fls. 157/158), assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 176/177).

Em audiência de instrução realizada por teleconferência, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 174/175), procedeu-se à inquirição das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e ao interrogatório do réu.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Sustentou que a atuação dos guardas civis municipais foi legítima, pois como qualquer um do povo, podem deter e prender pessoa em flagrante delito, o que não constitui ato investigativo, tendo citado jurisprudências do STF: RE 1259558 SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/03/2020; RE 1208225 SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/02/2020; HC 212642 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/03/2022. Ressaltou que o réu foi abordado em atitude típica de mercancia, em ponto de tráfico de drogas, quando estavam no local apenas ele e um motorista, estando na posse de porções de crack e quantia expressiva de dinheiro, sendo encontradas outras porções de drogas próximas a ele, de igual natureza e embalagem das que possuía, cujo consumo não afasta a imputação. Pleiteou a fixação da pena-base acima dos mínimos legais em razão dos maus antecedentes do réu; a incidência da agravante da reincidência; que não seja aplicado o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a cominação do regime inicial fechado de cumprimento de pena e o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Já a Defesa do réu, referindo o julgamento do REsp. 1977119 pelo E. STJ, em 16/08/2022, arguiu preliminar de nulidade das provas, pois obtidas em diligência de guardas civis municipais, sendo ilegal a abordagem e busca pessoal, e também não se enquadraria a hipótese na prisão por qualquer um do povo, dado que não havia visibilidade quanto ao crime de tráfico de drogas, tendo havido atos investigativos, como a busca pessoal. Subsidiariamente: sustentou que o réu deve ser responsabilizado apenas pelas drogas apreendidas em seu poder, pois não foi visualizado em contato com o maço que continha outras porções de drogas, e requereu a desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas para uso próprio: o réu afirmou ser usuário; estava em local frequentado por usuários; estava em poder de um só tipo de droga, em pequena quantidade; tem antecedentes por crimes patrimoniais de pequena monta e inquérito policial pelo porte de drogas para consumo pessoal, este arquivado recentemente; vive em situação de vulnerabilidade social. Em caso de condenação, requereu o arbitramento da pena-base nos mínimos legais; o aumento da pena pela reincidência no patamar de um sexto; a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.
Decido.

O réu é acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas.

Os guardas civis municipais que o abordaram, Sandro Henrique do Nascimento e Devanir Moreira dos Santos, narraram em sede policial que se deslocavam entre dois pontos públicos quando, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, presenciaram dois indivíduos em atitude suspeita, típica da mercancia ilícita. Um deles estava no banco do motorista de veículo estacionado, enquanto o outro com ele conversava pela janela. Abordados, em revista pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado com Luiz Gustavo Frare, indivíduo que estava no banco do motorista do automóvel, no qual havia um cheiro muito forte de drogas. Já com o indivíduo que estava do lado de fora do veículo, ora réu, em revista pessoal foram localizadas 06 porções de crack, bem como a quantia de R\$325,60. Logo ao lado do réu havia um maço de cigarros vazio, em que foram localizadas mais 52 porções de crack, idênticas

àquelas localizadas com o réu. Indagado sobre a procedência das substâncias e do dinheiro com ele localizado, o réu limitou-se a dizer que foi abordado por Luiz Gustavo para que lhe comprasse drogas, entregando-lhe a quantia em dinheiro com ele encontrada, porém, negou que as drogas lhe pertencessem. Contudo, Luiz Gustavo disse que apenas foi abordado pelo réu, não tendo qualquer envolvimento com o ocorrido (fls. 02 e 03).

Os mesmos guardas civis municipais foram inquiridos em juízo e apresentaram narrativas uníssonas às da fase policial. Em acréscimo, o GCM Sandro disse que o local dos fatos está situado entre dois pontos municipais e, ao utilizarem essa via em diligência, acabam fazendo a abordagem quando notam algo suspeito. O GCM Sandro foi quem realizou a busca pessoal no réu e também localizou, próximo a ele, o maço de cigarros contendo drogas; já o GCM Devanir foi o responsável pela busca veicular e pessoal no motorista. Inicialmente a abordagem foi realizada por apenas uma viatura. O réu estava na janela ao lado do carro, em via pública, e foi levado pelo GCM Sandro para a calçada do lado da via onde ele estava, a uma distância de cerca de dois metros, enquanto o GCM Devanir permaneceu na porta do motorista para evitar eventual fuga. Como o motorista do veículo era cadeirante, não poderia ser retirado do carro, então primeiro fizeram a revista pessoal no réu e posteriormente no motorista do veículo. Com o réu foram localizadas 06 porções de crack, que estavam em sua mão, das quais ele assumiu a propriedade. O GCM Sandro disse que o réu não mencionou a destinação das drogas, mas deduziu que – embora não localizado cachimbo com o réu – fossem para o próprio consumo devido ao local ser ponto de venda de drogas e frequentado por usuários, ao passo que o GCM Devanir disse que o réu a princípio alegou destinarem-se ao seu uso pessoal. Ao encostar o réu na parede a fim de fazer a busca pessoal, o GCM Sandro olhou para o lado e visualizou a caixa de cigarros, na mesma calçada, a cerca de meio metro de distância do réu, no final de uma planta espinhosa, entre a parede e essa planta. Ao abrir constatou mais drogas em seu interior, tratando-se de pedras de crack idênticas às que o réu possuía em mãos, já fracionadas para a venda. Todavia, o réu negou a propriedade dessas drogas.

De acordo com os guardas, o réu alegou que a quantia em dinheiro encontrada em seu poder do réu pertencia ao motorista do veículo, o qual lhe havia entregado com o fim de que comprasse pedras de crack para ele. O motorista, por sua vez, disse que o réu o abordou para solicitar um cigarro, negando a propriedade do dinheiro encontrado com o réu. Havia odor de entorpecente dentro do veículo, mas nenhum ilícito foi encontrado em seu interior. O GCM Devanir identificou que o cheiro provinha do automóvel, e não do réu, e se referia a aparente consumo de crack, não de cigarro. Ambos os guardas não visualizaram o motorista entregando cigarro ao réu, e não se recordaram se no veículo havia maço de cigarros. Não havia mais ninguém no local além dos abordados. O GCM Devanir nunca havia visto o réu anteriormente, enquanto o GCM Sandro já havia abordado o réu antes, duas ou três vezes, no mesmo local, quando nada de ilícito foi encontrado em seu poder e estava na companhia de outras pessoas. Os guardas informaram que não há comércio na rua dos fatos, apenas residências, sendo o comércio mais perto uma padaria de esquina, na rua de baixo. O GCM Devanir esclareceu que o motorista não precisaria passar pela rua dos fatos para manobrar.

Luiz Gustavo Frare, ouvido na delegacia como testemunha, declarou que conduzia seu veículo pelo local dos fatos quando o réu, que lhe era desconhecido, o abordou dizendo: “oh boy, me dá um cigarro!”. Encostou seu automóvel próximo ao meio-fio e deu um cigarro para o réu. Enquanto retirava o cigarro do maço, foram abordados por integrantes da Guarda Civil Municipal. Os guardas solicitaram que desembarcasse do veículo, mas por ser cadeirante não o fez. Nada de ilícito foi localizado em seu automóvel. O réu foi revistado e com ele foi localizada certa quantidade de drogas e dinheiro. Não havia entregado o dinheiro ao réu para que ele comprasse drogas, diversamente do que ele disse aos guardas. Nunca o tinha visto antes (fls. 04).

Em juízo Luiz Gustavo descreveu que havia acabado de comprar água e cigarro em comércio na rua dos fatos. Ao manobrar o automóvel o réu apareceu na janela e pediu um cigarro, ocasião em que surgiu uma viatura da guarda municipal. A princípio dois guardas municipais fizeram a abordagem, depois chegaram mais três viaturas em apoio. Em sua posse nada havia de ilícito, mas apenas dinheiro, cigarro e celular, este último apreendido. Permaneceu afastado do réu. O veículo foi vistoriado. Relatou aos guardas o que havia acontecido. Não foi possível escutar o que o réu disse aos guardas. Não sabe se havia ilícitos com o réu, embora o guarda lhe tenha afirmado que foram localizados e o conduziu até a delegacia, tendo solicitado que acompanhasse a equipe. Não sentiu cheiro de droga em seu veículo, apenas do cigarro comum que estava fumando e havia recém-comprado. Já tinha avistado o réu anteriormente, umas duas vezes, mas nunca haviam conversado. Desconhece se o local é conhecido como ponto de drogas, porém, é uma região em que há pessoas em situação de rua e inclusive que fazem o uso de entorpecentes. Já foi usuário de maconha, mas parou há um tempo considerável, devido a problemas de saúde, fazendo uso de cadeira de rodas. Consome apenas cigarros. Negou que estive comprando ou vendendo entorpecentes para o réu.

O réu permaneceu em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 05). Já em juízo assumiu somente a propriedade das seis porções de crack – dizendo destinarem-se ao seu próprio consumo – e da quantia de R\$325,00 em dinheiro, ambos apreendidos em seu poder. Negou a propriedade do maço contendo outras porções de crack, encontrado no chão da esquina, a cerca de 20 a 50 metros. Disse que é usuário compulsivo apenas de crack e coletava reciclagem desde o dia 14 de julho, vendendo-a no ferro-velho. Possuía seis porções de crack que havia adquirido no mercado, mas deslocou-se até o bairro Belém para adquirir mais drogas, a fim de não precisar ir muito à “biqueira”, porém, não chegou a comprá-las. Estava com as seis porções na mão quando passou por um veículo e pediu um cigarro para o motorista que desconhecia. Havia acabado de pegar o cigarro quando foi abordado pelos guardas municipais. Negou ter afirmado aos guardas que o motorista lhe deu o dinheiro, tendo assumido a propriedade da droga que estava em seu poder, dizendo ser usuário. Outra viatura encontrou o maço de cigarros com drogas e o exibiu para os guardas da abordagem inicial. Não percebeu cheiro de crack dentro do automóvel, e sendo usuário, o reconheceria. O dinheiro localizado no bolso de suas vestes provinha de venda de reciclagem e vigia de automóveis. Na rua da abordagem existem mercearias informais nas garagens das casas e na rua debaixo há uma padaria de esquina. É usuário de crack desde os 12 anos de idade e já chegou a ser internado. Encontrava-se em situação de rua, morando na praça Santa Terezinha. Estava em gozo de benefício, cumprindo pena por roubo.

Explicitadas as circunstâncias dos fatos de acordo com a prova oral produzida, a conclusão que deriva de sua análise é de que os guardas civis municipais não extrapolaram sua competência constitucional. Pelo contrário, agiram em atendimento ao interesse de coibir prática criminosa, de cuja ocorrência tiveram inequívoca ciência. Seria contrassenso exigir-se que, cientes de um crime e de seu objeto, permanecessem inertes aguardando providências por parte de outros agentes de segurança pública, com quem, evidentemente, podem colaborar.

Da prova oral depreende-se que os guardas municipais constantemente passavam pelo local dos fatos em diligência, porquanto localizado no percurso entre pontos públicos municipais. Cientes de que na localidade há constante tráfico e consumo de drogas, e tendo verificado situação típica de mercancia ilícita de substâncias entorpecentes – pela aparente troca de objetos –, acabaram abordando o réu e o motorista que se encontravam em via pública, sendo constatado que o réu detinha pedras de crack em uma das mãos, e mais drogas da mesma natureza e igual forma de embalagem foram localizadas nas suas proximidades.

A Guarda Civil, como órgão integrante da Segurança Pública, deve agir sempre que necessário para a proteção da integridade de seus municípios, além de que lhe é

resguardado, assim como a qualquer um do povo, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. No caso presente não restaram dúvidas de que os entorpecentes se encontravam de fácil acesso visual, posto que parte deles foi localizada nas mãos do réu, ao passo que as demais drogas estavam expostas em via pública, o que não torna a abordagem excessiva ou invasiva por parte dos guardas civis municipais. Não foram necessárias atividades investigativas para a apreensão dos ilícitos; a tanto bastou a simples abordagem do réu.

Não há ilegalidade, por eventual falta de competência, na diligência efetivada pelos guardas civis. Nesse sentido, há várias v. decisões posteriores ao entendimento manifestado pela C. 6ª Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.977.119/SP, publicado no DJe em 23/08/2022, inclusive ressaltando que é o entendimento pacífico da C. 5ª Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: STJ - HC: 776204 SP 2022/0319500-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 21/10/2022; STJ - HC: 731496 SP 2022/0086230-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 21/10/2022; STJ - REsp: 2017962 SP 2022/0243836-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30/09/2022; STJ - HC: 765855 SP 2022/0264860-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 16/09/2022; e STJ - AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp: 2084715 SP 2022/0068116-1, julgado em 23/08/2022, CE - Corte Especial, DJe 25/08/2022.

Destacam-se, a seguir, trechos relevantes e que embasam o quanto decidido:

"Recurso Especial nº 2017962 - SP (2022/0243836-2) Decisão. Trata-se de recurso especial interposto por [...]. Busca-se, no caso, a absolvição dos pacientes, diante da ilegalidade da abordagem realizada pelos guardas municipais, autoridades que não detêm competência para tanto. Na hipótese, observa-se que a Corte local, considerou legítima a atuação dos agentes da guarda municipal: "A preliminar não vinga. Inicialmente, não há que se falar em relaxamento da prisão, em razão da atuação dos Guardas Municipais, pois abordaram o acusado em flagrante delito, na posse e guarda dos entorpecentes. Ora, o artigo 301 do Código de Processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Assim, se qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, inexistirá óbice à realização de tal procedimento pelos guardas municipais, os quais, ressalte-se, compõem a segurança pública e, portanto, com mais razão devem zelar pela preservação da ordem." (fls. 55/56). Com efeito, observa-se que a atuação dos guardas municipais se baseou na autorização do art. 301, do Código de Processo Penal. A primeira parte do art. 301, do Código de Processo Penal, autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistirá ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa (AgRg no HC n. 667.413/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021) ou como polícia ostensiva. No caso, os agentes públicos encontraram os entorpecentes em abordagem pessoal dos pacientes, a qual foi precedida de dinâmica fática apta a fundar a justa e prévia suspeita da ocorrência de flagrante delito. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto da sentença condenatória: "Também não há ilicitude na prova produzida. A abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), o qual regulamentou o § 8º do art. 144 da Constituição Federal e permite o patrulhamento preventivo a fim de 'colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social' (inciso IV) e 'encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário' (inciso XIV). No caso dos autos, durante patrulhamento pelo local, visando a proteção da população local, os agentes municipais depararam-se com a situação flagrancial. Não fosse suficiente, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que, enquanto atuavam juntos para o narcotráfico, um deles vendendo drogas e o outro como olheiro, os investigados

encontravam-se em flagrante delito. Destaca-se, também, a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, diante da autorização prevista no art. 301 do Código de Processo Penal. [...] Os guardas municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) 'foi efetuada diligência ao local dos fatos em razão de já ter sido surpreendida ali a prática de venda de drogas em datas anteriores. [...]'. Se, no caso vertente, houve a fundada suspeita para a atuação da Guarda Municipal (alerta da aproximação dos agentes da lei, tentativa de fuga e de abandono do material entorpecente), inexistiu ilegalidade na prisão em flagrante realizada. [...] II - No caso vertente, houve a fundada suspeita para a atuação da Guarda Municipal, após denúncia com a descrição das vestes do paciente, encontrado em local conhecido pela mercancia ilegal e em atitude suspeita (mexendo em pedras do local, bem como tentou fugir após a aproximação dos agentes). Ademais, o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito. III - Com efeito, assente na jurisprudência deste Tribunal Superior que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistiu óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 2/4/2018). [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o recurso especial" (STJ - REsp 2017962 SP 2022/0243836-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30/09/2022 - Grifou-se).

"Habeas Corpus nº 731496 - SP (2022/0086230-9) Decisão. [...] No presente writ, o impetrante sustenta a ilicitude da prisão em flagrante, tendo em vista que realizada por guardas municipais, os quais fizeram atividade investigativa, considerando que, após recebimento de denúncia anônima, teriam abordado o ora paciente em via pública, não encontrando nada de ilícito, após o que teriam realizado busca em imóvel sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas razões que apontassem a situação de flagrância. Aponta a inadmissibilidade da atividade investigativa, com a realização de diligências por guardas civis, razão pela qual deve ser declarada a ilicitude das provas colhidas. [...] O Tribunal a quo assim consignou a respeito do flagrante feito por guardas municipais: "Inicialmente, não prospera a pretendida ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente realizada por Guardas Municipais. Isso porque a Guarda Civil atua como órgão integrante da segurança pública, prevista no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, devendo agir sempre que necessário para a proteção da integridade de seus munícipes, seja na prevenção ou na proteção da ordem pública. Ademais, os artigos 4º e 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014), dispõem sobre as atribuições da Guarda Municipal, ampliando o rol previsto no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Diante disso, compete à Guarda Civil, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; bem como desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal. [...] Portanto, em cognição sumária, não há se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da prisão em flagrante realizada. Outrossim, o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública. É cediço que o artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti; este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a r. decisão hostilizada, reproduzida a fls. 57/59, apresenta-se suficientemente fundamentada, considerando a presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados nas peculiaridades do caso concreto, reveladoras do acentuado grau de reprovabilidade da conduta atribuída ao Paciente. Aponta, ainda,

a considerável quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas (56 porções de maconha, 12 porções de skunk e 100 porções de cocaína), tudo a indicar a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública." Quanto ao tema, destaca-se que a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal. No caso, os agentes municipais receberam informações de que teria indivíduo traficando drogas no local, trajando camiseta preta "Lacoste" e calça preta de moleton. Assim que os guardas municipais chegaram no local, viram o paciente com as características informadas, o qual, assim que viu a viatura, tentou fugir do local. Após ser abordado, o paciente indicou o local onde as drogas estavam armazenadas, afirmando que assumiu o turno na biqueira no momento do flagrante. Diante desse contexto, tendo em vista que, até o momento, foram demonstrados elementos indicativos de justa causa para a abordagem e para o ingresso domiciliar, não é possível o provimento por esta Corte, tendo em vista que seria necessário maior aprofundamento na matéria fático-probatória para verificar a apontada ilicitude ocorrida, devendo tal providência ser realizada durante a instrução processual. Nesse sentido, trago à colação julgados de ambas as Turmas que examinam matéria penal: [...]. Dessa forma, inexistente flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. Por tais razões, não conheço do habeas corpus" (STJ – HC 731496 SP 2022/0086230-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 21/10/2022 - Grifou-se).

Reconhecida a higidez da diligência e das provas amealhadas, assenta-se que, em que pese o réu tenha negado a prática do tráfico de drogas, o conjunto probatório indica o contrário.

O motorista Luiz Gustavo alegou que havia adquirido produtos em um ponto comercial da rua dos fatos e manobrava seu automóvel quando foi interpelado pelo réu, o qual lhe pediu um cigarro, que de acordo com o réu havia recém-recebido, quando foram abordados.

Em consulta ao aplicativo Google Maps verificou-se que a área em que se deu a abordagem é residencial; o comércio mais próximo – uma padaria – situa-se na rua debaixo, descendo o morro. Conforme o GCM Devanir mencionou, não haveria necessidade de o motorista adentrar na rua dos fatos para manobrar o automóvel, e não se mostra crível que, em condição de vulnerabilidade física, dado que é cadeirante, iria deixar o vidro aberto para conversar com um desconhecido, em área onde não havia circulação de pessoas – uma vez delineado que não havia outras pessoas nas proximidades – e em que tinha conhecimento ser usual a prática do tráfico de drogas. Além disso, os fatos aconteceram em uma tarde de domingo, dia de descanso da população e de habitual fechamento de estabelecimentos comerciais, até mesmo de eventual comércio informal na rua dos fatos, cuja existência, aliás, não foi observada pelos guardas municipais que constantemente passam pelo local.

Ademais, os guardas não visualizaram qualquer entrega de cigarros do motorista do veículo ao réu, nem o réu estava na posse de cigarros, nem os guardas se recordaram de caixa de cigarros no interior do automóvel, o que não passaria despercebido, ainda mais pelo odor que seu interior exalava e constatado pelos guardas.

Não se olvida, ainda, que o motorista do carro referiu ter sido usuário de entorpecentes no passado, apesar da aparente tentativa de rechaçar essa condição quando dos fatos. No momento da abordagem, o réu foi surpreendido na posse de seis porções de crack – devidamente embaladas para a venda a terceiros – que estavam em suas mãos, entorpecente que certamente não deixaria de fácil visualização a terceiro desconhecido a quem supostamente apenas pedia um cigarro.

Para afastar a imputação da prática da traficância o réu alegou que as drogas se destinavam ao seu próprio consumo, as quais havia recém-adquirido no mercado

municipal da cidade. Todavia, não se mostra razoável que, ao invés de fazer o imediato consumo das drogas – o que se espera de um dependente químico-toxicológico – o réu se deslocaria por longa distância, em uma caminhada de quase uma hora, segundo informe obtido em consulta no aplicativo Google Maps, a fim de adquirir mais drogas. Ainda, se as drogas se destinavam ao seu consumo, razão não havia para que as mantivesse em suas mãos, e não resguardadas junto ao seu corpo ou vestes.

Conquanto a defesa tenha alegado que dentre os antecedentes criminais do réu há inquérito policial pelo porte de drogas para consumo pessoal, recentemente arquivado, tratando-se dos autos nº 1502611-94.2019.8.26.0482, da Vara do Juizado Especial Criminal de Presidente Prudente, observa-se que os fatos versados naquela sede ocorreram em 2019, assim como o arquivamento do expediente, havendo se passado mais de três anos até a ocorrência de que ora se cuida, ou seja, não há a recentidade apontada. Some-se a isso que o consumo de entorpecentes não é incompatível com a prática da traficância, atividades que muitas vezes coexistem e se financiam.

O réu também portava considerável quantia em dinheiro, que aos guardas municipais disse pertencer ao motorista do veículo, de quem teria recebido para que lhe comprasse drogas, o que não teria ocorrido caso não lhe fosse fornecer os entorpecentes, tanto é que estes já estavam em suas mãos, não havendo mais ninguém no local, além dos abordados e dos guardas municipais, que pudesse ser qualificado como potencial fornecedor das drogas.

Em audiência judicial o réu modificou a justificativa sobre a quantia em dinheiro, dizendo ser oriunda das atividades de vigia de carros e venda de reciclagem. No entanto, o réu estava na posse de considerável valor (R\$325,60) - cuja origem lícita, embora com oportunidade, não comprovou - e que não se compatibiliza com a condição de alguém que declarou estar em situação de vulnerabilidade e sem local para residir. Não se olvide que o dinheiro estava em notas trocadas, característica típica da prática do tráfico de drogas (fotografia a fls. 18).

O réu não era pessoa conhecida do GCM Devanir, e havia sido abordado anteriormente pelo GCM Sandro em situação em que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, segundo descreveram. Apesar do contexto, restou evidenciado que os guardas civis não procuraram prejudicar o réu indevidamente, ou relacioná-lo ao tráfico injustamente; pelo contrário, apontaram a possibilidade de que o réu estivesse no local na condição de usuário, não havendo motivos para se duvidar de suas narrativas.

Todavia, as circunstâncias da abordagem, já referidas, denotam a prática da traficância. Não bastasse, embora o GCM Sandro tenha abordado o réu e com ele contornado o veículo estacionado em via pública, encostando-o na parede para realizar a busca pessoal, o local de abordagem era bem próximo à esquina onde foi localizado o maço contendo mais porções de crack, que estava na planta espinhosa citada pelo referido guarda, a qual inclusive pode ser vista em pesquisa no Google Maps, situando-se em lado oposto ao terreno mencionado pela defesa. O maço de cigarros continha 52 porções de crack, as quais – além de localizadas próximas ao réu –, possuíam a mesma natureza e estavam embaladas da mesma forma das 06 porções de crack apreendidas nas mãos do réu (fotografias a fls. 16 e 19).

É certo que o réu não assumiu a propriedade do maço de cigarros contendo mais entorpecentes, diversamente do que se verificou com as drogas que estavam diretamente em seu poder. No entanto, é de comum conhecimento a conduta de traficantes de permanecer com pequena quantidade de drogas em mãos, mantendo a maior parte escondida em local próximo, para que, em caso de abordagem, possam alegar que as poucas porções de drogas localizadas em seu poder seriam para consumo pessoal – exatamente como se verificou na hipótese – e assim afastar a imputação da prática do comércio ilícito de entorpecentes.

O conjunto probatório, todavia, revela que o réu estava no local – já conhecido pelo tráfico de drogas – realizando a venda de entorpecentes, e que o maço contendo mais porções de crack, idênticas às que o réu levava consigo, era de sua propriedade, ainda mais porque não havia outra pessoa nas imediações que pudesse eventualmente ser a proprietária do citado maço, e cujo conteúdo, pela sua quantidade e valor, certamente não seria esquecido ou deixado abandonado no local por terceiro.

De todo modo, mesmo que não se admitisse que as drogas encontradas junto à vegetação local pertenciam ao réu, restou bem evidenciada a traficância.

A materialidade também restou comprovada, porquanto a respeito da conduta delitiva foram lavrados Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01) e Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), registrando-se a apreensão, em poder do réu, de R\$ 325,60 em dinheiro (comprovante de depósito judicial a fls. 97) e 06 pedras de crack, também sendo apreendido um maço de cigarros vazio com 52 porções de crack, além de um aparelho celular preto da marca Samsung de propriedade de Luiz Gustavo Frare (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 17 e Fotografias a fls. 18/21).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 13/16), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 185/187), identificou-se que a droga apreendida em poder do réu tratava-se, efetivamente, de cocaína, pois “foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)”.

Frente ao exposto, incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu deve ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas.

Passo à dosimetria das penas, com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação das penas observa-se que o réu estava em poder de crack, substância entorpecente cujos efeitos deletérios sobre o organismo humano são muito mais drásticos que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil. Todavia, trazia consigo quantidade, seja de 1,8g ou de 16,4g, que não se pode reputar exorbitante do ordinário, o que não é motivação suficiente para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Por outro lado, a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 138/143) e a Folha de Antecedentes (fls. 120/137) relacionadas ao réu demonstram que é portador de maus antecedentes por crimes patrimoniais: (i) tentativa de roubo - autos nº 0006546-22.2008.8.26.0445, da 1ª Vara Cível de Pindamonhangaba, cuja pena foi cumprida em 16/03/2011; (ii) tentativa de furto - autos nº 0004608-29.2011.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, com pena cumprida em 26/12/2012; (iii) tentativa de furto - autos nº 0008493-82.2006.8.26.0445, da 2ª Vara Cível de Pindamonhangaba, com cumprimento de pena em 23/07/2015.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é multirreincidente, pois ostenta condenações por: (i) furto, nos autos nº 0003242-49.2007.8.26.0445, da Vara Criminal de Pindamonhangaba, cuja pena foi cumprida em 14/09/2017; (ii) roubo, nos autos nº 0080906-36.2014.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda de São Paulo, com pena cumprida

14/09/2021; e (iii) furto, nos autos nº 0009683-46.2007.8.26.0445, da Vara Criminal de Pindamonhangaba, com r. sentença condenatória transitada em julgado em 13/10/2014 para o Ministério Público e em 23/03/2015 para a defesa, cuja pena estava sendo cumprida com progressão ao regime aberto quando voltou a delinquir.

Reconhecida a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), múltipla na hipótese, elevo as penas de um quarto, isto é, a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Não há atenuantes a considerar, pois o réu não confessou a posse de todas as drogas apreendidas em seu poder, e em nenhum momento admitiu que pretendia destiná-las à venda e ao consumo de terceiros, não demonstrando qualquer intenção de colaborar com a justiça do caso ou o menor arrependimento (STJ, Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio).

A múltipla reincidência do réu impede, objetivamente, a aplicação à hipótese da causa especial de diminuição de penas preconizada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto demonstra que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, não havendo, portanto, causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar, as quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Aplicada pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos e sendo o réu multirreincidente, incabível a substituição por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

O réu é multirreincidente e cumpria pena em regime aberto quando voltou a delinquir. Tais fatores, aliados à quantidade de pena aplicada, implicam deva cumprir a pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, pois demonstra ausência de senso de responsabilidade, além de que as pretéritas condenações não se mostraram suficientes a coibir novas práticas delitivas por parte do réu.

Inviável, nesta ocasião, a análise da detração da pena (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º), já que desconhecido deste juízo o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento de eventual direito derivado do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, não se olvidando que o réu registra outra pena pendente de cumprimento.

Havendo nos autos informes de que a situação econômica do réu não é privilegiada (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido em poder do réu, porque não se comprovou tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Deixo de determinar a perda do aparelho celular preto da marca Samsung, pois de propriedade da testemunha Luis Gustavo Frare e não do réu.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Cláudio Ferreira da Silva à pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em

regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 728 dias-multa, com cálculo unitário no mínimo legal, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º, §9º). A exigibilidade dessa verba permanecerá sob condição suspensiva, enquanto perdurar a insuficiência de recursos que justifica a concessão da gratuidade da justiça ao réu, tal como pleiteado em audiência, e já que assistido pela Defensoria Pública (anote-se); ao cabo de cinco anos, subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, remanescendo a hipossuficiência financeira, poderá ser reconhecida sua inexigibilidade, o que fica a cargo do Juízo das Execuções.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Está sendo condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual. Além disso, é multirreincidente e voltou a delinquir enquanto cumpria outra pena antes imposta, o que denota ausência de comprometimento com a manutenção da ordem pública e com a aplicação das leis penais.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, oficiando-se.

Ao trânsito em julgado:

i) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$325,60, bem declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 17, com comprovação de depósito a fls. 97.

ii) providencie a Serventia para que seja restituído o aparelho celular da marca Samsung ao seu proprietário, a testemunha Luis Gustavo Frare.

iii) oficie-se à autoridade policial, comunicando-lhe a autorização para que seja destruída a droga remanescente, armazenada para eventual contraprova.

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 16 de dezembro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA